

<제10장 부작위위법확인소송 및 기타소송.제01절 부작위위법확인소송>

[예상][10.01-1]부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계

《[문제10.1]

부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계에 대해서 논하시오.》

<문제10.1> 부작위위법확인소송과 행정심판전치주의의 관계

I. 부작위위법확인소송의 의의와 절차적 특성

- 행정소송법상 부작위위법확인소송은 행정청이 당사자의 신청에 대하여 상당한 기간 내에 일정한 처분을 하여야 할 법률상 의무가 있음에도 불구하고 이를 하지 아니하는 부작위 상태가 위법함을 확인하는 소송이다. 이는 처분의 부존재라는 특수한 상태를 다루므로 제소기간이나 전치절차의 적용에 있어 처분을 대상으로 하는 취소소송과는 다른 법리적 쟁점이 발생한다. 특히, 행정소송법 제38조 제2항이 행정심판전치주의를 규정하는 제18조를 명시적으로 준용하지 않고 있음에도 불구하고, 실무와 이론상 전치주의의 적용이 긍정되는 배경과 그 구체적 실천 방안인 의무이행심판과의 연계성을 고찰할 필요가 있다. 이하에서는 부작위위법확인소송에서 전치주의가 적용되는 근거와 절차적 요건에 대하여 논한다.

II. 행정소송법 제38조 제2항의 조문 해석과 쟁점

1. 조문상 준용 규정의 결여

- 행정소송법 제38조 제2항은 부작위위법확인소송에 준용되는 조항들을 나열하고 있으나, 취소소송의 행정심판전치주의를 규정하고 있는 제18조를 포함하고 있지 않다. 이러한 조문 구조만 보면 문언상 부작위위법확인소송에서는 행정심판을 거칠 필요가 없는 것처럼 보일 수 있다.

2. 입법적 불비와 해석의 필요성

- 조문상 제18조가 누락된 이유에 대하여 입법상의 실수(입법 과오)라는 견해와 부작위의 특성상 처분이 존재하지 않으므로 전치주의를 적용하기 곤란하기 때문이라는 견해가 대립한다. 그러나 개별 법률에서 필요적 전치주의를 규정하고 있는 경우와의 충돌 문제, 그리고 행정소송법 제20조 제2항이 부작위위법확인소송에서 행정심판을 거친 경우의 제소기간을 규정하고 있는 점 등을 고려할 때 해석을 통한 보완이 요구된다.

III. 부작위위법확인소송에서 전치주의가 적용되는 근거

1. 행정소송법 제20조 제2항의 존재

- 행정소송법 제20조 제2항은 부작위위법확인소송에 대하여 제소기간을 적용하지 않으면서도, 다만 행정심판을 거친 경우에는 행정심판 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 소를 제기하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 법 스스로 부작위위법확인소송에 행정심판 절차가 선행될 수 있음을 예정하고 있는 강력한 근거가 된다.

2. 행정심판법상 부작위에 대한 심판 청구권

- 행정심판법은 행정청의 거부처분이나 부작위에 대하여 의무이행심판을 제기할 수 있도록 규정하고 있다. 따라서 행정소송법 제38조 제2항의 준용 규정 누락에도 불구하고, 국민은 행정심판법에 의거하여 부작위 상태에 대해 행정심판을 청구할 권리를 가진다.

3. 필요적 전치주의 규정과의 조화

- 국세, 관세, 도로교통법상의 처분 등 개별 법률에서 `행정소송을 제기하기 전에 반드시 행정심판을 거쳐야 한다`고 규정하고 있는 경우, 해당 부작위 역시 그 법률의 적용을 받는 대상이 되므로 전치주의가 적용되는 것으로 해석함이 타당하다. 사법부는 이러한 개별법상의 필요적 전치 규정이 있는 경우 부작위위법확인소송에서도 이를 준수해야 한다고 판단한다.

IV. 의무이행심판과 부작위위법확인소송의 연계

1. 부작위에 대한 행정심판의 형태

- 부작위위법확인소송에 대응하는 행정심판은 부작위위법확인심판이 아니라 의무이행심판이다. 행정심판법은 부작위에 대해 위법 여부만을 확인하는 소극적 심판 대신 행정청에 직접 처분을 명하는 적극적 구제 수단인 의무이행심판을 제도화하고 있기 때문이다.

2. 의무이행심판의 제기 요건

- 당사자는 행정청의 부작위에 대하여 기간의 제한 없이 의무이행심판을 청구할 수 있다. 이때 심판위원회는 부작위가 위법하거나 부당하다고 판단되면 처분을 직접 하거나 처분을 할 것을 명하는 재결을 내리게 된다. 부작위위법확인소송에서 전치주의를 충족하기 위해서는 바로 이 의무이행심판을 거쳐야 한다.

3. 전치 절차로서의 기능

- 부작위위법확인소송에서 행정심판전치주의가 적용되는 경우, 원고는 의무이행심판을 청구하여 기각 재결 등을 받은 후 그 재결서 정본을 송달받은 날부터 90일 이내에 소를 제기함으로써 제소기간 요건과 전치 요건을 동시에 충족하게 된다. 만약 의무이행심판에서 인용 재결이 나왔음에도 행정청이 처분을 하지 않는다면, 이는 별도의 부작위 문제이므로 다시 다투어야 한다.

V. 판례 및 실무적 태도

1. 필요적 전치주의 사안에서의 태도

- 판례는 개별 법률이 행정심판전치주의를 채택하고 있는 경우, 부작위위법확인소송이라 하더라도 행정심판을 거치지 않고 소를 제기하면 부적법 각하 판결을 내린다. 법 조문상의 준용 규정 미비보다 개별법상의 강행 규정과 국민의 권리 구제 체계를 우선시하는 입장이다.

2. 제소기간과의 상관관계

- 부작위위법확인소송은 원칙적으로 제소기간의 제한을 받지 않으나, 행정심판을 거치게 되면 제소기간의 제한(90일)이 발생한다. 이는 행정심판을 거침으로써 부작위의 위법 여부에 대한 공적인 판단이 한 번 내려졌으므로, 그 이후의 소송 제기는 신속하게 확정되어야 한다는 법적 안정성의 논리가 반영된 것이다.

3. 실무상 유의사항

- 변호사나 당사자는 부작위 상태를 다룰 때 해당 사안이 필요적 전치주의 대상인지를 반드시 확인해야 한다. 만약 국세 사건처럼 전치주의가 필수적인 사안에서 의무이행심판을 거치지 않고 곧바로 부작위위법확인소송을 제기하면 승소 가능성과 상관없이 형식적 요건 미비로 소가 종료될 위험이 크다.

VI. 학설상의 쟁점 및 비판적 검토

1. 준용 규정 누락에 대한 입법론

- 다수설은 행정소송법 제38조 제2항에서 제18조를 누락한 것을 명백한 입법 과오로 본다. 부작위는 처분이 존재하지 않으므로 전치주의를 적용할 객체가 없다는 소수설도 있으나, 행정심판법이 의무이행심판을 통해 부작위를 심판 대상으로 삼고 있는 이상 논거가 부족하다는 평가를 받는다.

2. 전치주의 적용의 정당성

- 행정심판은 행정청 내부의 자율적 통제 기회를 부여하고 사법부의 부담을 경감하는 기능이 있다. 부작위 사안에서도 행정심판위원회가 행정청의 부작위 원인을 분석하여 신속한 처분을 유도할 수 있으므로 전치주의를 적용하는 것이 정책적으로도 타당하다.

3. 의무이행소송 도입과의 관계

- 향후 행정소송법 개정을 통해 의무이행소송이 도입된다면 부작위위법확인소송의 입지는 좁아질 것이다. 현재 부작위위법확인소송과 의무이행심판의 부조화(소송은 확인만, 심판은 이행까지)는 제도의 불균형을 초래하고 있으며, 전치주의 해석 역시 이러한 제도적 과도기에서 발생하는 혼란의 일부이다.

VI 결론

- 행정소송법 제38조 제2항의 명문 규정에도 불구하고 부작위위법확인소송에서 행정심판전치주의가 적용되는 것은 법체계의 통합적 해석과 국민의 실효적 권리 구제를 위한 결과이다. 행정소송법 제20조 제2항이 전치 절차를 거친 경우의 제소기간을 명시하고 있고, 개별 법률이 필요적 전치주의를 요구하는 현실에서 조문상의 준용 규정 누락만을 근거로 전치주의를 부정하는 것은 타당하지 않다. 따라서 부작위 상태에 놓인 당사자는 행정심판법에 의한 의무이행심판을 청구하여 행정청의 응답을 촉구하거나 법적 판단을 받아야 하며, 이를 거친 후에는 엄격해지는 제소기간 내에 소송을 제기해야 한다. 이러한 법리는 행정청의 부작위로부터 국민을 보호하는 동시에 사법 절차의 객관성을 유지하는 균형점이 된다. 결국 부작위위법확인소송에서의 전치주의 문제는 단순한 조문 해석을 넘어 행정구제 제도 전체의 조화로운 운영이라는 관점에서 이해되어야 한다.